2024년 특허·상표
판례연구논문 공모전
우수논문집

Intellectual Property
Trial and Appeal Board

05

장려상

배 솜 이

원출원에서 공지예외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지예외주장의 허용 여부

판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결
제 목	원출원에서 공지예외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지예외주장의 허용 여부
요 약	특허법 제30조는 특허출원 전에 발명이 공개된 발명자를 보호하기 위한 공지예외제도를 규정하고 있다. 공지예외를 적용받기 위해서는 같은 조 제2항에 따른 공지예외 주장 시기를 준수하는 것이 원칙이나, 그 시기를 놓친 원출원의 분할출원에서 공지예외 주장을 새롭게 허용할 수 있는지에 대해서는 상반된 판결들이 존재해 왔다. 특히, 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(이하 '대상 판결')은 이러한 논쟁의 핵심적인 판결로, 원출원에서 공지예외 주장 시기를 경과한 후에도 분할출원에서 공지예외를 새롭게 주장할 수 있다고 판단하여 긍정론의 입장을 취하였다. 본 논문에서는 이 판결을 중심으로, 국내외 유사 판례와 학설을 바탕으로 긍정론과 부정론을 비교·분석하였다. 이를 통해 특허법 제30조의 공지예외제도와 제52조의 분할출원제도에 대한 이해를 바탕으로, 대상 판결의 논거가 타당하지 않음을 논증하였다. 무엇보다도, 특허법 제30조가 규정하는 절차적 요건은 반드시 준수되어야 하며, 이를 무력화하는 법 해석은 허용될 수 없다. 절차적 요건에 대한 예외를 인정하기 위해서는 입법자의 명확한 의도가 반영된 규정이 필요하며, 특허법 제200조에서 허용하는 '특례'가 그 예이다. 특허법 제52조 제2항은 제30조가 규정하는 절차적 요건에 예외를 두기 위한 것이 아니라, 분할출원 시에도 새로운 취지 주장과 증명서류 제출이 필요함을 명확히 규정한 것이다.
필 요 성	대상 대법원 판결은 비록 원출원에서 공지예외를 주장할 수 있는 시기를 놓친 경우에도 분할출원 시 새롭게 공지예외를 주장할 수 있다고 설시한 중요한 판결이다. 그러나 이 판결은 특허법 제30조가 규정하는 절차적 요건을 무의미하게 만들 수 있기 때문에, 향후 특허청 및 특허심판원이 이 판결을 따를 것인지, 아니면 이에 반하는 실무를 유지할 것인지에 대한 명확한 입장이 필요하다. 본 논문은 대상 판결의 긍정설에 내재된 법적 오류를 하나하나 반박하였다. 본 논문이 향후 특허심판원이 부정설에 기반한 실무를 유지하고, 더 나아가 대법원이 대상 판결의 오류를 스스로 시정하는 새로운 판결을 내리는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

독 창 성	대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에 대해 비판적 견해를 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결에 대해 비판적 견해를 제시한 논문은 거의 없는 상황이며, 기존 두 논문은 모두 대상 판결을 지지하는 입장을 취하고 있다. 본 논문은 기존 연구에서 다루지 않았던 일본의 유사 판례를 국내 판례와 비교·분석하고, 일본과 우리나라의 제도적 유사성에 주목하여 두 제도를 상세히 비교하였다. 이를 통해 본 논문은 대상 판결에 대한 새로운 관점을 제시하고, 기존 연구와 차별화된 논거를 제시하였다.
파급효과	대상 판결로 인해 원출원에서 공지예외를 주장할 시기를 놓친 경우, 분할출원을 통해 새롭게 공지예외를 주장하는 사례가 다수 발생할 것으로 예상된다. 이러한 새로운 주장에 대해 특허청과 특허심판원은 대상 판결의 법리를 따를 것인지, 아니면 특허법 제30조 제2항의 절차적 요건을 우선시하여 그 주장을 인정하지 않을 것인지에 대한 명확한 입장을 정해야 한다. 본 논문은 특허청과 특허심판원이 부정설에 따른 실무를 채택할 수 있기를 기대하며, 나아가 대법원이 대상 판결의 오류를 스스로 시정하는 새로운 판결을 선고하기를 바란다. 본 논문은 입법부가 규정한 공지예외제도의 절차적 요건이 입법자의 의도대로 관철되게 하는 효과를 가진다고 생각한다.

장 려 상

원출원에서 공지예외주장의 시기 경과 후, 분할출원에서 새로운 공지예외주장의 허용 여부

대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결

목 차 / Contents

1. 서 론 ····· 219
2. 공지예외제도 관련 현행 법리의 문제점 특정 ····· 220
가. 특허법 제30조 공지예외제도
나. 특허법 제52조 분할출원제도
다. 분할출원에서의 공지예외적용
라. 쟁점의 특정
3. 해당 쟁점에 대한 판례 법리 ····· 226
가. 변전시스템 학술대회 사건
나. 석사학위논문 분할출원 사건 (대법원 2020후11479 판결)
4. 일본의 상응 제도 및 판례 검토 ···· 236
가. 제도
나. NK세포 활성화제 사건
5. 긍정론과 부정론 비교 및 분석 ····· 242
가. 긍정론
나. 부정론
다. 소결
6. 결 론 ····· 253
가. 공지예외와 분할출원의 법적 쟁점 재해석
나. 국제특허출원의 공지예외제도에 관한 특례
다. 분할출원의 공지예외적용 3가지 분류 및 허용 기준 제안

1 서 론

특허법 제30조는 발명자가 출원 전에 자신의 발명을 공개한 경우에도 일정 요건을 충족하면 그 발명을 특허받을 수 있도록 하는 공지예외제도를 규정한다. 이러한 공지예외제도는 발명자가 본인의 연구성과를 공개한 후에도 특허를 받을 수 있는 기회를 제공함으로써 발명자 보호와 연구활동 촉진이라는 중요한 목적을 지향한다. 그러나 공지예외의 적용을 받기 위해서는 같은 조 제2항이 규정하는 절차적 요건을 준수해야 한다.

원출원에서 그 절차적 요건을 준수하지 못한 경우에도 분할출원 시 공지예외를 새롭게 주장할 수 있는지에 대해 이견이 있었다. 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결(이하, '대상 판결')은 이러한 논란의 중심에 있는 판결로, 원출원에서 공지예외주장의 시기를 놓친 경우에도 분할출원 시 새롭게 주장할 수 있다고 판단하여 긍정론의 입장을 취하였다. 대상 판결은 공지예외제도와 분할출원의 관계에 대한 기존의 해석과 실무에 중대한 영향을 미쳤다. 본 논문은 대상 판결이 타당한 것인지 여부를 점검하는 것을 목적으로 한다.

본 논문은 공지예외제도와 분할출원제도에 대한 문제점을 검토하고, 관련 판례와 일본의 유사 제도 및 판례를 분석하여 해결법리를 모색하고자 한다. 먼저, 특허법 제30조가 규정하는 공지예외제도와 제52조가 규정하는 분할출원제도의 개정 전·후를 비교하고, 분할출원 시 공지예외 적용의 쟁점을 도출한다. 이러한 검토를 통해, 변전시스템 학술대회 사건과 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후11479 판결)에서 법원이 제시한 법리를 분석한다.

이어 일본의 공지예외제도와 분할출원에 관한 규정을 검토하고, NK세포 활성화제 사건과 같은 주요 판례를 통해 일본 법제와의 차이점과 시사점을 도출한다. 이를 바탕으로, 긍정론과 부정론의 입장을 비교·분석하여 분할출원에서의 공지예외적용 문제에 대한 법적 타당성을 논증하고, 각 입장의 논거를 체계적으로 검토한다.

결론적으로, 본 논문은 대상 판결이 지닌 법적 오류를 지적하고, 향후 특허청 및 특허심판원이 공지예외제도와 분할출원제도의 관계를 명확히 정립하는 데 기여하고자 한다. 이를 통해 공지예외제도의 절차적 요건이 입법자의 의도에 맞게 적용될

수 있도록 하고, 발명자 보호와 제도의 안정성이라는 두 가지 목표를 조화롭게 달성할 수 있기를 기대한다.

2 공지예외제도 관련 현행 법리의 문제점 특정

가 특허법 제30조 공지예외제도

발명은 특허법 제29조(특허요건)에 따라 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 모두 충족하여야 특허로 등록될 수 있다. 이에 따라, "특허출원 전에 국내외에서 공지(公知)된 발명"은 신규성을 충족하지 못하고, 그러한 발명으로부터 용이하게 도출할 수 있는 발명은 진보성을 충족하지 못하여 특허를 받을 수 없다.[1] 그러나 이러한 특허의 요건을 발명자가 인지하지 못하여 출원 전에 논문, 학술 대회, 세미나 등에 공개하게 된 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우 그 공개로 인해 특허등록이 거절되는 것이 원칙이나, 발명자가 특허제도에 무지하여 자신의 발명을 스스로 공개하게 되거나 발명자의 의사에 반하여 발명이 공개되어 특허를 받지 못하는 것은 발명자에게 너무 가혹하다. 또한 이러한 경우 예외를 인정하지 않게 되면 발명자는 연구결과의 신속한 공개를 기피하는 결과를 초래할 수 있다. 이는 국가 산업발전의 촉진이라는 특허법의 목적에 어긋나므로 특허법 제30조는 공지에 대한 예외를 규정한다.[2] 제30조가 규정하는 제도는 "신규성 상실의 예외", "신규성 의제"[3], "유예기간"등의 용어로 칭하고 있다. 그러나 어떤 제도를 지칭하는 용어는 통일되어야 하므로 본 논문은 특허청 심사기준과 동일하게 "공지예외"라는 용어로 통일하여 지칭한다.[4]

---

1) 특허법 제29조 제1항 제1호("특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 제2호 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명").

2) 특허청 특허제도과, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 3228면; 정차호, "IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도", 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013, 33면.

3) 이규호 외 3명, "우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설", 특허청 연구보고서, 2007, 195면.

"공지예외기간"이란, 발명의 공개일로부터 특허를 받을 수 있는 출원일까지의 기간을 의미한다. 공지예외기간은 당초 6개월이었으나, 한·미 FTA를 반영하여 2011년 개정에서 12개월로 연장하였다.[5] 공지예외적용이 인정되는 공개 범위는 특허법 제29조 제1항 각호에 따라 공개된 모든 발명에 해당한다. 과거에는 공개 범위를 제한하고 있었으나 현재는 이러한 제한을 완화하여 공개된 모든 발명에 대해 공지예외를 인정하고 있다. 공지예외적용을 위해서는 일정 기간 내에 공지예외를 적용받겠다는 공지예외주장을 해야한다.(공지예외주장을 할 수 있는 기간을 '공지예외주장시기'라고 칭함) 공지예외주장시기는 제30조 제2항에서 규정하고 있으며, 공지예외주장의 취지를 특허출원 시 출원서에 기재하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다.[6] 또한 동조 제3항에 따라 보완수수료를 납부하는 조건으로 공지예외주장에 대한 보완이 가능하다. 보완수수료를 납부한 경우에는 보정기간 또는 특허결정, 특허거절결정, 취소심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 공지예외적용을 위한 취지기재 또는 증명서류 제출이 가능하다.

나 특허법 제52조 분할출원제도

(1) 분할출원제도의 취지 및 연혁

둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우, 이는 "1발명 1출원" 원칙에 위배되어 특허거절결정이 내려진다.[7] 특허법 제52조가 규정하는 분할출원 제도는 이러한 상황에서 출원인을 구제하기 위해 마련된 것이다. 출원인은 최초 출원서에

4) 윤기승, "특허법상 공지예외적용에 관한 연구", 국제법무 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019, 57면; 정차호, "IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도", 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013, 32면.

5) 한·미 FTA 협정문(제18.8조 제7항)

6) 특허법 제30조 제2항("제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 산업통상자원부령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.").

7) 특허법 제45조 제1항("특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.").

첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서, 특정 기간 내에 해당 출원의 일부를 하나 이상의 출원으로 분할할 수 있다. 이 제도는 발명에 대한 일정 기간의 독점권을 부여하는 특허제도가 발명의 공개를 그 대가로 한다는 점에서, 출원 당시 청구범위에 기재되지 않았지만 발명의 설명 또는 도면에 포함된 발명도 보호받을 수 있도록 마련된 것이다.[8] 따라서, 출원인이 둘 이상의 발명을 하나의 출원으로 한 경우, 이를 1발명 1출원 원칙에 맞게 분할하고, 그 분할된 출원의 출원일을 원출원의 출원일로 소급하여 인정함으로써 출원인에게 불리함이 없도록 구제한다.[9] 아래의 표는 분할출원의 개정 방향을 정리한 것이다.

〈표 1〉 분할출원제도의 연혁

연도	내용
1952년 제49조[10]	2 이상의 발명 또는 고안을 포함한 특허출원을 분할할 경우, 각 분할출원은 최초 출원일에 출원된 것으로 간주한다고 규정하였다.
1961년 제56조[11]	특허권자의 착오로 하나의 출원에 여러 발명이 포함된 경우, 각 발명별로 특허권을 분할할 수 있도록 규정하였다.
1974년 제10조[12]	분할출원이 최초 출원일로 소급 적용될 수 있도록 규정을 마련하여, 분할출원의 법적 기반을 확립하였다. 그러나 반의사(비자발)공지의 경우 공지예외제도 적용 시 출원일을 소급하지 않도록 하였다.[13]
2001년 제52조[14]	신규사항추가금지 및 최후거절이유통지 등 엄격한 보정제도를 도입하여 분할출원의 이용 형태를 다양화하였다.[15]
2006년 제52조[16]	분할출원이 가능한 범위를 "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내"로 한정하였다.
2009년 제52조[17]	분할출원 기간을 특허거절결정 송달일부터 심판청구기간까지 확대하였다.
2014년 제52조[18]	1. 외국어특허출원에 대한 규정 추가: 외국어특허출원 시 국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원을 할 수 있도록 개정하였다. 2. 분할출원 가능기간 축소: 거절결정등본 송달일부터 30일 이내, 연장 시 제15조 제1항에 따른 기간까지로 제한하였다. 3. 우선권 주장 서류 제출기간 연장: 우선권을 주장하여 분할출원을 할 경우, 제54조에 따른 서류를 분할출원일로부터 3개월 이내 제출하도록 허용하였다. 4. 명세서 보정 허용 범위 확대: 최초 명세서에 청구범위가 없는 분할출원은 제42조의2 제2항 기간 후에도 분할출원일로부터 30일 이내 청구범위 보정 허용하였다.

8) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6102-6103면.
9) 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017, 169면.

2021년 제52조[19]	1. 분할출원 가능기간 연장: 특허거절결정등본을 송달받은 후 30일 이내였던 분할출원 가능 기간이 3개월 이내로 연장하였다. 2. 우선권 주장 규정 신설: 분할의 기초가 되는 특허출원이 우선권을 주장한 경우, 분할출원도 우선권을 주장한 것으로 간주하며, 우선권 주장 취하 및 관련 서류 제출 기한을 규정하였다.

(2) 분할출원제도의 절차 및 효과

특허출원에 대한 분할출원은 주체적 요건, 시기적 요건, 객체적 요건을 충족하여야 한다. 주체적 요건은 분할출원을 할 수 있는 자에 대한 요건으로, 원출원을 한 자 또는 그 승계인이 분할출원을 할 수 있다.[20] 시기적 요건은 출원일에 따라 구분되며, 2022년 4월 20일 기준으로 특허결정등본 송달 전까지, 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간, 재심사 청구 시, 거절결정 송달 후 3개월 이내, 그리고 특허결정등본 송달 후 3개월 이내의 기간(단, 설정등록 이전)에 한하여 가능하다.[21] 또한,

10) 구 특허법(1961. 12. 31. 시행 전) 제49조("2이상의 발명, 고안을 포함한 특허 출원을 2이상의 출원으로 분할하였을 시는 각 출원을 최초의 출원 당시에 한 것으로 차를 간주함.").

11) 구 특허법(1963. 4. 5. 시행 전) 제56조.

12) 구 특허법(1976. 12. 31. 시행 전) 제10조.

13) 구 특허법(1976. 12. 31. 시행 전) 제10조 제1항("2이상의 발명을 1출원에게 한 자가 이를 2이상의 출원으로 분할 출원한 경우에는 그 분할 출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 제7조 제2항 또는 제42조의 제1항 및 제2항의 규정에 해당하는 경우에는 예외로 한다.").

14) 구 특허법(2002. 7. 1. 시행 전) 제52조.

15) 김동준, "특허법상 분할출원제도 개선방안", 경영법률 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008, 2면.

16) 2006년 구 특허법(2007. 4. 11. 시행 전) 제52조 제1항("특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위안에서 제47조제1항의 규정에 의하여 보정을 할 수 있는 기간 이내에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다.").

17) 2009년 구 특허법(2013. 3. 22. 시행 전) 제52조 제1항 제2호("특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간").

18) 2014년 구 특허법(2015. 7. 29. 시행 전) 제52조.

19) 2021년 구 특허법(2022. 10. 18. 시행 전) 제52조 제1항 제2호("특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간"); 제52조 제4항; 제52조 제5항.

20) 특허청 특허제도과, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6103면("공동출원의 경우에는 원출원과 분할출원의 출원인 전원이 완전히 일치하여야 한다.").

21) 특허청 특허제도과, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6104면.

분할출원의 기초가 되는 원출원은 분할출원 시점에 특허청에서 계속 중인 상태여야 한다. 따라서 원출원이 무효, 취하, 포기되거나 거절결정이 확정된 경우에는 분할출원을 할 수 없다. 분할출원의 객체적 요건은 분할되는 출원이 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있어야 한다. 분할출원의 적법성 판단 기준은 원출원일에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 내용이다. 따라서 보정으로 삭제된 발명은 분할출원할 수 있으나, 보정으로 새롭게 추가된 발명은 원출원에 포함되지 않았으므로 분할출원의 대상이 되지 않는다.[22]

분할출원의 절차를 받기 위해서는 분할출원서에 그 취지와 원출원의 표시를 하고, 명세서, 요약서 및 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.[23] 분할출원으로 인해 원출원의 명세서 등을 보정할 필요가 있는 경우, 일반적으로 분할출원과 동시에 보정이 이루어진다. 다만, 분할출원의 발명이 원출원의 명세서나 도면에만 기재되어 있고 청구항에 포함되지 않은 경우에는 보정이 필요하지 않다. 조약우선권이나 국내우선권을 주장한 경우, 원출원에서 제출된 서류는 분할출원에도 제출된 것으로 간주된다.[24] 만약 우선권 주장 서류를 제출하지 않았더라도, 분할출원일부터 3개월 이내에 제출하면 된다.[25] 또한, 최초 명세서에 청구범위를 기재하지 않은 경우에도 분할출원일로부터 30일 이내에 청구범위 보정이 가능하다.[26]

분할출원의 효과는 분할이 적법한 경우, 분할출원이 원출원일에 출원된 것으로 간주된다는 점이다.[27] 비록 분할출원이 원출원보다 늦게 이루어지지만, 원출원의

---

22) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6105면.

23) 특허법 제52조 제3항.

24) 특허법 제52조 제4항; 조영선, 『특허법 3.1』, 박영사, 2023, 291면(“종래에는 원출원에서 공지예외주장 또는 우선권주장에 대한 절차를 밟았다 하더라도 분할출원이 이러한 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 했으나, 2021. 10. 19 개정 특허법(법률 제18505호)은 이를 위와 같이 변경하여 출원인의 편의를 도모하고 있다.”).

25) 특허법 제52조 제6항.

26) 특허법 제52조 제8항.

27) 특허법 제52조 제2항(“제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.
1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
2. 제30조제2항을 적용하는 경우
3. 제54조제3항을 적용하는 경우

일부를 분리하여 출원하는 것이므로, 분할출원은 원출원일에 출원된 것으로 본다. 따라서 분할출원의 신규성, 진보성 및 선출원 요건은 원출원의 출원일을 기준으로 판단되며, 제3자가 이를 이유로 이의를 제기할 수 없다. 또한, 출원공개 시기, 출원심사청구기간, 존속기간의 기산점도 원출원의 출원일을 기준으로 한다.[28]

다 분할출원에서의 공지예외적용

분할출원이 공지예외적용을 받으려면, 원출원 시 공지예외 적용 취지를 기재하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하면 된다. 원출원 시 공지예외주장에 대한 증명서류를 제출했다면, 분할출원 시 해당 증명서류는 그 취지를 명기함으로써 갈음할 수 있다.[29] 다만, 특허 심사실무에서는 원출원 시 취지 기재와 증명서류 제출을 하지 못했더라도, 공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어진 경우에는 분할출원 시 취지 기재 및 증명서류 제출을 허용하고 있다. 2017년 이전의 특허 심사 실무에서는 분할출원에 대해 공지예외적용을 받기 위해서는 원출원 시에만 공지예외주장을 인정하였다.[30] 그러나 2017년 이후, 특허청은 2015. 7. 29. 이후 출원된 원출원을 기초로 하는 분할출원의 경우 원출원 시 공지예외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있도록 심사 실무를 개선하였다.[31]

라 쟁점의 특정

앞서 살펴본 바와 같이, 특허법에는 분할출원 시 공지예외적용에 대한 명시적 규

4. 제55조제2항을 적용하는 경우”).

28) 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017, 173면.

29) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023, 6107면(“분할출원에 대하여 제출하여야 할 공지예외주장 또는 조약우선권주장에 대한 증명서류의 내용이 원출원에 대하여 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 해당 서식의 첨부서류란에 그 취 지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다.”).

30) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 94호, 특허청, 2016, 6106-6107면.

31) 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 97호, 특허청, 2017, 6106면.

정이 존재하지 않는다. 특허 심사실무에서는 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 이를 허용하고 있으나, 이에 대한 법리적 근거가 부족하다. 특히, 2015년 7월 29일 이후부터는 원출원 시 공지예외주장이 누락된 경우에도 분할출원 시 공지예외주장을 허용하는 방향으로 심사기준이 변화하였다. 이러한 명시적 규정의 부재와 심사 실무의 변화는 출원인에게 혼란을 초래할 뿐만 아니라, 제도의 운영이 법 해석에 따라 변동될 수 있다는 점에서 신속한 해결이 필요하다. 이에 본 논문은 분할출원의 공지예외적용과 관련된 국내외 판례 및 학설을 검토하고, 그 법적 쟁점을 명확히 하여, 분할출원에서 공지예외를 인정할 수 있는지 여부에 대한 합리적 기준을 도출하고자 한다.

3 해당 쟁점에 대한 판례 법리

가 변전시스템 학술대회 사건(대법원 2010후2353 판결)

(1) 사실관계

본 사건에서 발명자는 출원발명과 관련된 연구 결과를 2006년 5월 26일과 27일 대한전기학회 전기설비 전문위원회 춘계학술대회에서 "IEC61850 기반 디지털 변전시스템에서의 PDMS 적용 방안에 관한 연구"라는 제목으로 발표하고, 동일한 기간에 학회 논문집에 게재하였다. 해당 발명은 2006년 6월 21일 특허출원 제2006-0056030호로 출원되었으나, 공지예외적용을 주장하는 취지가 누락된 채 출원되었고, 대리인을 통해 출원일 다음 날인 6월 22일에 증명서류를 제출하였음에도 불구하고 2008년 9월 29일 특허법 제29조 제2항에 따른 진보성 결여로 거절되었다.[32] 청구인은 이 거절결정에 불복하여 심판을 청구하면서, 특허출원 요건 자료를 대리인에게 제공하였으나 절차가 제대로 진행되지 않아 공지된 것이므로, 특허법 제30조 제1항 제2호에 따른 출원인의 의사에 반한 공지로 간주하여야 한다

32) 특허법 제29조 제2항("특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.").

고 주장하였다. 이에 대해 특허법원은, 출원인이 자신의 발명을 학술회의에서 발표하였음에도 불구하고 공지예외적용을 위한 취지가 기재된 특허 출원서를 제출하지 않았음을 지적하면서, 청구인이 제출한 자료에는 당초 공지예외적용 취지가 기재되어 있었으나 특허청 제출 시 누락되었다는 주장을 받아들이지 않았다.

청구인은 특허법 제30조 제1항 제2호 반의사(비자발) 공지의 공지예외적용에 따라, 대리인에게 모든 내용을 위임하였음에도 공지예외적용을 위한 절차가 진행되지 않아 발명이 공지된 것이므로, 공지되지 않은 발명으로 간주하여야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 출원인이 공지예외적용 의사를 대리인에게 명확히 전달했는지 확인할 수 없고, 다른 자료에서도 대리인이 출원인의 의사에 반해 공지예외적용 취지를 누락했다고 인정할 근거가 없다고 판단하였다.

따라서, "대리인은 출원인을 대신하여 특허출원 절차를 수행하며, 그 결과는 출원인 본인의 행위와 동일한 효력을 가진다. 공지예외적용을 주장하는 취지가 기재된 출원서를 특허청에 제출하지 않았다면 이를 출원인의 의사에 반한 공지라고 할 수 없다."라는 원결정을 정당하다고 보고 공지예외적용을 인정하지 않으며 원고의 심판청구를 기각하였다. 이후 원고는 특허심판원에서 청구가 기각되자 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 원고 승소 판결을 내렸다.

(2) 쟁점

이 사건의 주요 쟁점은 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조의 공지예외규정이 적용되는지와, 의사(자발) 공개에 의한 공지예외적용을 위한 취지 기재 누락이 출원 후 보정 가능한지 및 그 보정이 적법한지 여부이다.[33]

(3) 양당사자 주장

원고는 이 사건 출원에서 공지예외주장을 위한 취지 기재가 형식적으로 누락되었더라도, 공지예외적용을 위한 증명서류를 제출한 만큼 공지예외적용이 인정되어야 한다고 주장하였다. 원고는 출원인의 신뢰 보호 필요성, 출원인의 명확한 공지예외적용 의사의 추정 가능성, 이익형량의 심각한 훼손 방지, 특허법 제30조의 취지 및 특허법의 목적 등을 고려하여, 공지예외의 취지가 실질적으로 기재된 것으로

33) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.

간주하여야 한다고 주장하며, 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 따른 공지예외가 적용되어야 한다고 주장하였다.[34]

이에 대해 피고는, 특허법 제30조 제2항에 따라 자기 공지에 의한 공지예외규정을 적용받기 위해서는 그 취지를 반드시 특허출원 시 출원서에 기재해야 하며, 출원서에서 해당 기재를 누락한 후 이를 보정할 수 없다고 주장하였다. 따라서 출원일 다음 날 출원인이 공지예외적용을 위한 증명서류를 제출했더라도, 이 사건 출원발명에 대해 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외 적용을 받을 수 없다고 다투었다.

(4) 특허법원의 판단(긍정론)[35]

특허법원은 이 사건 출원발명이 특허법 제30조 제1항 제1호의 공지예외적용을 받을 수 있다고 판단하여 원고의 청구를 인용하는 결정을 내렸다. 특허법원의 구체적인 판단 근거는 다음과 같다.

(가) 특허법 제30조의 취지에 따라 공지예외적용을 위한 취지 기재의 보정이 허용되어야 한다.

특허법 제29조 제1항 및 제2항은 특허제도가 존재하지 않더라도 기술 진보를 방해하지 않아야 한다는 원칙을 규정하고 있으므로, 특허 발명이 공중에게 제공되는 혜택보다 특허권자의 독점으로 인한 부작용이 크지 않아야 한다. 그러나 발명이 출원 전에 공지되었다는 이유만으로 특허권을 부여하지 않는 것은 발명자에게 과도한 불이익을 초래하며, 이는 산업 발전을 저해할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 특허법 제30조는 일정 요건을 충족하는 경우, 공지되지 않은 것으로 간주하는 공지예외 제도를 도입하고 있다.

2006년 개정 전 특허법에서는 제30조 제1항에서 공개 형태를 '시험, 간행물 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면 발표, 박람회 출품' 등으로 제한하고 있었다.[36] 그러나 2006년 개

34) 특허법원 2011. 8. 24. 선고 2011허5953 판결.
35) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.
36) 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것.

정 이후에는 공개의 형태에 대한 제한을 없애고, 발명자가 자신의 기술을 공개하더라도 이를 공지예외로 인정하여 발명 보호의 실효성을 확보하고자 했다.[37] 이는 발명자가 출원 전 자유롭게 기술을 공개하여 연구 활동을 촉진하고자 하는 특허법 제30조의 취지와 일치한다. 또한, 특허법 제30조 제1항은 "공지일로부터 6개월 이내에 특허출원할 것"과 제2항은 "특허출원서에 공지예외적용을 주장하는 취지를 기재할 것"이라는 절차 요건을 규정하고 있다. 이러한 요건은 절차적 규정이므로, 이를 출원 후 보정할 수 없다고 해석할 경우 제도의 본래 취지를 약화시킬 우려가 있다. 따라서 출원 후에도 공지예외적용을 위한 취지 기재의 보정이 허용되어야 하며, 이는 발명자 보호와 기술 진보 촉진이라는 특허법의 목적에 부합한다.

(나) 공지예외주장에서 보정을 허용하지 않는 것은 발명자에게 불이익을 끼치며 형평성에 어긋난다.

출원 시 공지예외주장을 누락한 것은 절차상 형식적인 하자에 불과함에도 불구하고 이를 보정할 수 없도록 하여 특허를 받을 수 없게 하는 것은, 출원발명의 실질적 내용과 무관하게 특허 취득 기회를 박탈하는 것으로, 발명자에게 중대한 불이익을 초래할 수 있다. 특히, 출원인이 출원 전에 자신의 공지가 의사(자발) 공지에 해당하는지 명확히 인식하지 못하거나, 실수로 공지예외 주장의 취지를 기재하지 못한 경우 등을 고려할 때, 특허법 제30조 제2항에서 규정하는 공지예외주장의 취지 기재를 반드시 출원 시에만 가능하도록 해석하는 것은, 반의사(비자발) 공지의 경우와 비교해 형평성에 어긋난다.

(다) 출원시 취지기재를 하지 않았다고 절차가 불가능한 것은 아님

특허법 제30조 제2항에서 요구하는 공지예외적용에 대한 취지 기재는 실체심사 단계에서 심사관이 특허 요건을 판단할 때 필요한 사항이며, 출원 시부터 반드시 구비되어야만 절차 진행이 가능한 사항은 아니다. 또한, 출원서에 취지 기재를 하지 않은 경우 보정을 허용하더라도, 공지예외기간 내에 특허 출원을 한 출원인에게 공지예외 효력을 부여하는 것이므로 제3자의 권리에 부당한 영향을 미치지 않는다.

---

37) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결("2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정법은 공개 형태를 특정한 경우로 한정하는 제한을 없애고 모든 형태의 자발적 공개 행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 함으로써 자기 공지에 의한 공지예외 규정의 실질적 실효성을 확보하였고").

(라) 공지예외주장 취지 기재에 대해 명시적인 규정이 없음

특허법 시행령과 시행규칙에서 공지예외주장에 대해 출원 후 보정하는 것을 명시적으로 금지하고 있지 않기 때문에 취지 기재의 누락을 보정하도록 허용하는 것이 타당하다.

(5) 대법원의 판단(부정론)[38]

대법원은 특허법 제30조 공지예외제도가 출원과는 별개의 절차이므로, 특허출원서에 공지예외 적용 취지를 기재하지 않은 경우 이는 통상의 출원으로 간주되어, 공지예외 주장 절차가 따로 존재하지 않으므로 출원 후 보정은 허용될 수 없다고 판단하였다. 이에 따라 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다.

(가) 공지예외적용을 주장하는 것은 출원과는 별개의 절차이다.

특허법 제30조 제1항 제1호에 따른 의사(자발) 공개에 대한 공지예외주장이 특허출원서에 기재되지 않은 경우, 해당 출원은 공지예외적용을 받을 수 없다. 또한, 특허법 제30조 제2항에서 요구하는 절차를 이행하지 않고 이를 보정하려는 시도는 공지예외 적용을 받을 수 없다는 점에서 동일하다.

대법원은, 원고가 이 사건 출원발명의 특허출원서에 공지예외주장을 하지 않고 출원한 이상, 이후에 공지예외의 취지를 기재한 서면을 제출하더라도 특허법 제30조 제1항 제1호의 적용을 받을 수 없다고 판단했다. 공지예외주장은 출원과 별개의 절차이며, 공지예외적용을 위한 취지 기재가 없는 특허출원은 공지예외주장이 없는 통상의 출원으로 간주된다. 따라서 공지예외적용에 관한 절차가 출원 후 별도로 존재하지 않으며, 이에 대한 보정도 허용되지 않는다. 결과적으로, 특허출원서에 공지예외적용을 위한 취지 기재가 없으면 공지예외적용을 받을 수 없고, 제30조 제2항의 절차를 이행하지 않았을 경우에도 절차 보정을 통해 공지예외적용을 받을 수 없다.

38) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결.

나 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후11479 판결)

(1) 사실관계[39]

이 사건에서 원고는 2014년 8월 1일에 석사학위 논문을 발표하여 발명을 공지하였고 이로부터 1년 이내인 2014년 12월 23일에 동일한 내용에 관하여 특허출원(제10-2014-186799호)하였다. 이때 원고는 공지예외주장을 하지 않았고 증명서류도 제출하지 않았다. 특허청 심사관은 선행발명으로 원고 본인의 상기 석사학위논문에 기재된 발명을 들어, 출원발명의 신규성·진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 이에 대하여 원고는 2016년 8월 30일에 상기 특허출원(원출원)에 기초하여 분할출원의 형식으로 특허출원(제10-2016-111145호)을 하면서 공지예외주장을 하였고 그 증명서류로서 원고 본인의 석사학위논문을 제출하고 원출원을 취하하였다. 그러나 특허청 심사관은 2017년 3월 15일 원출원 당시에 공지예외주장을 하지 않아 분할출원시 공지예외주장을 할 수 없으므로 그 주장을 무효로 한다는 취지의 통지(무효처분통지서)를 하고 이어서 원고의 석사학위논문의 선행발명에 의하여 분할출원된 발명의 신규성·진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 이에 원고는 의견서를 제출하였고, 심사관이 위 의견서에 의하여 다시 심사하였으나 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 이 사건 출원 발명에 대한 거절결정을 하였다. 한편 원고는 2018년 9월 17에 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020년 3월 3일에 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명에 의해 신규성 및 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

(2) 쟁점

이 사건에서는 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우, 공지로부터 1년이 경과된 후의 분할출원 절차에서 공지예외를 새롭게 주장할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.

39) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

(3) 양당사자 주장

원고는 다음의 세 가지를 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호 규정에 따른 공지예외가 적용되어야 한다고 주장하였다. ① 특허법은 분할출원이 적법하게 출원되고 정해진 기간 내에 공지예외주장을 하면 분할출원도 공지예외주장을 인정한다는 규정만 두고 있을 뿐, 원출원과 연관하여 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원도 공지예외주장이 인정되지 않는다는 어떠한 규정도 없다. ②분할출원의 공지예외주장은 원출원과 별개로 진행해야 하며 공지예외주장이 특허법 제30조 제2항에 맞게 적법하게 이루어진 것이라면, 공지예외주장 또한 인정되어야 한다. ③2015. 1. 28. 법률 제13096호로 신설된 특허법 제30조 제3항의 규정 취지에 비추어 볼 때, 위 조항의 시행일(2015. 7. 29.) 이후에 분할출원된 이 사건 출원은 공지예외가 인정되어야 한다.

피고는 이러한 원고의 주장에 대해 이와 관련된 특허법 규정들의 취지와 관련 법리에 비추었을 때, 분할출원이 적용받을 수 있는 공지예외 효과는 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다는 것일 뿐, 원출원 시 공지예외주장 절차를 누락했다면 분할출원에서 그와 같은 절차를 밟았다고 하더라도 공지예외의 효과를 주장할 수는 없는 것으로 봄이 타당하다고 주장하였다.

(4) 특허법원의 판단(부정론)[40]

특허법원은 제30조 제1항 제1호의 공지예외 규정의 적용 여부에 대해 아래의 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호에서 정한 공지예외 규정이 적용되지 않는다고 판단하였다.

(가) 분할출원의 입법취지는 공지예외적용을 위한 회피수단이 아님

특허법원은 “분할출원은 원출원으로부터 분할되지만 원출원과는 별개의 것이므로 원출원에 대하여 밟은 절차상의 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니다.”라고 언급하며 원출원에서 공지예외제도의 절차를 밟았어도 분할출원의 효력을 누리기 위해서는 또다시 절차를 밟아야 한다고 주장하였다. 또한 분할출원일

40) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

부터 공지예외주장 절차를 밟을 수 있도록 허용하는 이유는 분할출원의 효과에 따라 원출원일로 소급 적용하게 되면 분할출원시 취재야 하는 절차의 시기가 앞당겨져 공지예외주장 절차를 밟지 못하게 되는 것을 막기 위함이다. 따라서 특허법 제52조 제2항의 입법취지는 원출원시 공지예외주장을 했을 때 분할출원시 할 수 없게 되는 문제를 해결하기 위함이지, 원출원시 공지예외적용의 취지 기재를 누락한 것을 회피할 수 있도록 하는 수단이 아니라고 보았다.[41]

(나) 특허법 제30조 제2항 규정의 형해화 우려

앞서 대법원 판례에서 부정론의 논거로 제시하였던 공지예외적용의 주장은 출원과는 별개의 절차라는 논거가 본 판결문에 사용되었다.[42] 요약하면 2015년 개정으로 인해 특허법 제30조 제3항이 신설되기 전에는 공지예외주장은 출원과 별개의 절차이므로 출원시 취지 기재가 없다면 주장이 없는 통상이 출원이 되고, 따라서 이에 관한 절차가 존재하지 않아 보정 또한 허용될 수 없다는 해석을 참고한 것이다. 또한 특허법 제30조 제3항이 신설되었음에도 분할출원을 통해 이러한 공지예외주장 시기에 관한 규정을 우회할 수 있게 된다면, 원출원시 공지예외주장을 하지 않은 것을 분할출원을 통해 보정할 수 있게 되는데, 이러한 효과는 특허법 제30조 제2항 규정을 형해화 할 수 있다고 보았다.

(다) 특허법 제30조 제3항의 취지는 분할출원의 공지예외적용에 대한 허용이 아님

특허법 제30조 제1항에서 규정하는 공지예외제도는 "출원인의 이익을 위해 원칙 에 대한 예외로서 존재하는 제도로, 출원인으로서는 이러한 이익을 향유하기 위하여 법이 정하는 요건을 충족하여야 한다.[43]"특허법 제30조 제3항은 공지예외적용의 취지 기재를 출원시 실수로 누락한 경우 이를 보완하기 위해 보정할 기회를 주고 있으나, 소급적용할 경우 법적 안정성을 저해하는 것을 방지하지 위하여 시행일 후 출원한 특허부터 적용하도록 부칙으로 정하고 있다. 이러한 입법취지를 고려

41) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허 3072 판결("2) 분할출원은 원출원으로부터 분할되지만 원출원과는 별개의 것이므로 원출원에 대하여 밟은 절차상의 효력이 분할출원에도 당연히 승계되는 것은 아니다…").

42) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결.

43) 김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 8면.

하면 특허법 제30조 제3항이 시행일 이후 분할출원된 모든 발명에 대해 원출원시 공지예외주장을 했는지의 여부를 불문하고 공지예외규정을 적용할 수 있다는 것으로 해석할 수는 없다.

(5) 대법원의 판단[44](긍정론)

이 사건에 대해 대법원은 공지예외 및 분할출원 관련 규정의 문언과 내용, 각 제도의 취지 등에 비추어 보면, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법한 절차를 준수하여 공지예외주장을 하였다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 이내에 이루어진 이상 공지예외의 효과를 인정받을 수 있다고 봄이 타당하다고 판단하였다.

(가) 분할출원의 공지예외주장은 분할출원일을 기준으로 판단되어야 함

대법원은"특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다"고 정하고 있을 뿐,[45] 공지예외주장을 원출원이 아닌 분할출원에서만 한 경우, 요건 충족 여부에 대해 원출원일을 기준으로 정하고 있지 않다는 점을 논거로 제시하였다. 따라서 문언상으로 해석했을 때 원출원 시 공지예외주장이 이뤄지지 않았더라도 분할출원이 적법하게 이뤄졌다면 특허법 제52조 제2항에 따라 원출원일에 출원한 것으로 보는 것이다. 결론적으로 "자기공지일로부터 12개월 이내에 원출원이 이루어지고, 분할출원일을 기준으로 공지예외주장의 절차 요건을 충족하였다면, 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌다 하더라도 공지예외의 효과가 발생하는 것으로 해석함이 타당하다."고 판단하였다.

(나) 원출원 시 미처 권리화하지 못한 발명에 대한 보호 수단으로 작용할 수 있음

분할출원은 1발명 1출원주의에 대한 구제수단으로 활용하기도 하지만, 원출원

44) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

45) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결("이는 공지예외주장의 시기 및 증명서류 제출 기한을 원출원일로 소급하여 산정하면 분할출원 시 이미 그 기한이 지나있는 경우가 많기 때문이다").

당시 청구범위에 기재되지 않았으나 원출원 시 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재되어 있는 발명을 후일 권리화할 이유가 생긴 경우 해당 발명에 대해서도 원출원과 같은 효과를 인정하도록 허용하여 특허제도로 보호할 수 있도록 하고 있다. 따라서 원출원을 할 당시에는 청구범위가 공지된 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았지만, 분할출원을 할 때에는 청구범위가 이미 공지된 내용에 포함되어 있을 경우가 생길 수 있고, 이러한 경우를 보호할 수 있도록 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았어도 분할출원에서 이를 인정할 실질적 필요성이 있다.

(다) 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려에 대한 근거 부족

앞서 학술대회 사건에서 부정론을 제시하였던 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결에서는 분할출원은 특허에 대한 절차의 보정과는 별개의 제도로, 보정 가능 여부와 무관하게 특허요건을 충족한다면 독립된 출원으로 허용할 수 있다고 해석하였다. 이와 같은 관점에 따라 분할출원을 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 것에 대한 보정의 수단으로 사용하는 것은 특허법 제30조 제2항을 형해화할 우려가 있어 허용될 수 없다고 판단하였다. 그러나 대법원은 이러한 근거가 분할출원에서의 공지예외주장을 허용하지 않을만한 근거가 되지 못한다고 판단하였다.

(라) 분할출원의 공지예외주장과 특허법 제30조 제3항의 신설은 별개의 제도임

대법원 2010후2353 판결 이후, 출원인의 권리보호를 위하여 특허법 제30조 제3항이 신설되어 출원 시 공지예외주장을 미처 하지 못했더라도 일정 기간에 이를 보완할 수 있는 제도가 도입되었다.[46] 그러나 이러한 특허 절차에서의 보정과 분할출원은 별개의 제도이며 그 요건과 취지가 다르다는 점에 비추어 볼 때, 공지예외주장을 원출원이 아닌 분할출원시 한 경우 그 효과를 원출원일 기준으로 인정받을 수 있는가에 관한 여부는 특허법 제30조 제3항의 신설과 별개로 일관되게 해석해야 한다고 주장하였다.

---

46) 특허법 제30조 제3항("제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다.
1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간").

(마) 현재 공지예외규정은 실효적인 발명자 보호 제도로 자리매김함

공지예외제도는 제정 이후 현재까지 공개의 범위뿐만 아니라 그 기간과 절차 요건까지 계속해서 완화하고 있다.[47] 또한 특허제도에 미숙한 발명자에 대한 보호를 넘어 실효적인 보호 제도로 자리매김 하고 있다는 점을 고려하면, 분할출원시 공지예외주장을 하는 것을 원출원 시 하는 것과 동일한 효과를 인정하는 것을 제한할 합리적 이유를 찾기 어렵다는 것이 대법원의 판단이다.

4 일본의 상응 제도 및 판례 검토

가 제도

(1) 일본의 공지예외제도: 특허법 제30조

일본은 우리나라와 유사한 공지예외제도를 채택하고 있으며, 일본 특허법 제30조에서 규정하고 있다. 일본에서는 발명의 공개일부터 출원일까지의 공지예외기간을 12개월로 설정하고 있으며, 공지예외를 주장하려면 출원 시 공지예외 적용 취지를 기재하고, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다. 우리나라는 현재 공지예외주장에 대한 보완기간을 두고 있지만, 일본은 반드시 출원과 동시에 공지예외주장을 해야한 다는 점에 차이가 있다. 다만, 제30조 제4항에서는 부득이한 사유로 인해 증명서류를 제출하지 못한 경우, 해당 사유가 해소된 날로부터 14일 이내(재외자는 2개월 이내)에, 정해진 기간이 경과한 날로부터 최대 6개월까지 증명서류를 제출할 수 있는 보완기간을 두고 있다.[48]

47) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결("공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다.").

48) 일본 특허법 제30조 제4항("④ 증명서를 제출하는 자가 그 책임을 질 수 없는 이유에 의해 전항에서 규정하는 기간 내에 증명서를 제출할 수 없을 때에는 동항의 규정에도 불구하고 그 이유가 없어진 날로부터 14일(재외자의 경우 2개월) 이내로 그 기간의 경과 후 6개월 이내에 그 증명서를 특허청장에게 제출할 수 있다.").

(2) 일본의 분할출원제도에서의 공지예외제도(일본 특허법 제44조)

일본 특허법 제44조에 따르면, 분할출원은 원출원일에 출원된 것으로 간주된다. 다만 공지예외의 경우 절차의 적용을 위해 새로운 특허출원과 동시에 제출된 것으로 본다.[49] 일본 심사실무에 따르면, 원출원 시 공지예외 적용을 위한 취지 기재나 증명서를 제출하지 않았더라도, 발명 공개 후 1년 이내에 분할출원을 하며 이를 수행하면 공지예외 적용이 가능하다. 그러나 공개 후 1년이 지난 시점에서 분할출원을 하며 절차를 수행할 경우 공지예외적용을 받을 수 없다.[50] 2017년 일본 특허법 개정 전에는 공지예외 기간이 6개월로 현재보다 짧았으나, 당시에도 분할출원에서 공지예외 적용은 허용되었다.[51]

(3) 한국과 일본의 분할출원제도에서의 공지예외제도 비교

한국과 일본의 심사실무에서는 원출원시 공지예외의 취지기재와 증명서류를 제출하지 못하더라도 분할출원 시 공지예외주장을 할 수 있도록 허용하고 있다. 다만 두 나라 간에는 허용 기간에 차이가 있다. 일본은 발명의 공개일부터 분할출원일까

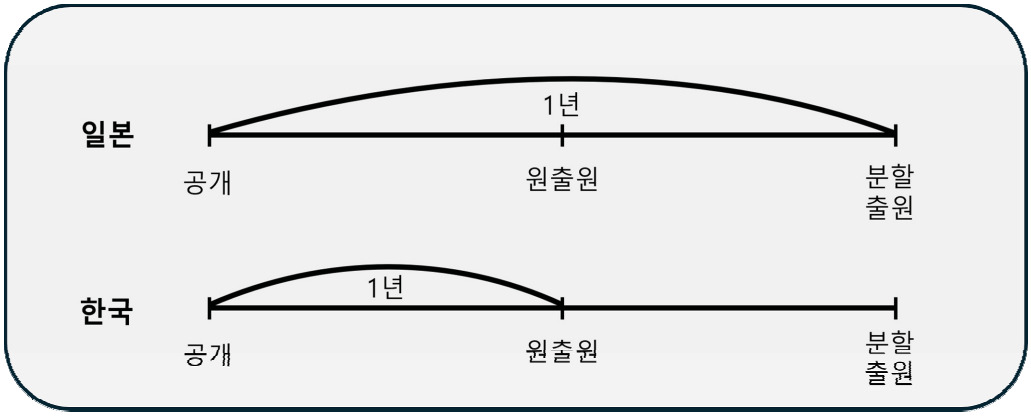
49) 일본 특허법 제44조("제1항의 경우에는 새로운 특허출원은 원래의 특허출원 시에 한 것으로 본다. 다만, 새로운 특허출원이 제29조의2에서 규정하는 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제3조의2에서 규정하는 특허출원에 해당하는 경우의 이들 규정의 적용 및 제 30조제3항 규정의 적용에 대해서는 그러하지 아니한다.").

50) 特許庁, "平成 30年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き", 2020, p.14("5.2 分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願の場合 原出願の出願に際して手続 ([2.]の(a)~(c)) を行えば、分割出願／変更出願／実用新 案登録に基づく特許出願を行う際には、再度の手続は不要です (特許法第 44 条第 4 項、第 46 条第 6 項、第 46 条の 2 第 5 項) 。 また、原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開 日から 1 年以内に分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願をして手続 ([2.] の(a)~(c)) を行えば、第 2 項の規定の適用を受けることができます。なお、原出願の出 願に際して手続をせずに発明の公開日から 1 年経過後に分割出願／変更出願／実用新案登 録に基づく特許出願をした場合は、第 2 項の規定の適用を受けることができません。"); 特許庁, "特許・実用新案 審査基準", 2020, p.7("4.3.4 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願 分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願の場合は、原出願の出 願日である。 ただし、原出願において「証明する書面」が提出されていない場合は、現実の出 願日である。").

51) 特許庁, "平成 23年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き", 2013, p.14("また、原出願に際して手続を行っていなかった公開された発明については、発明の公開 日から 6 月以内に分割出願／変更出願／実用新案登録に基づく特許出願をして手続 ([2.] の(a)~(c)) を行えば、第 2 項の規定の適用を受けることができます。なお、原出願の出 願に際して手続をせずに発明の公開日から 6 月経過後に分割出願／変更出願／実用新案登 録に基づく特許出願をした場合は、第 2 項の規定の適用を受けることができません。").

지의 기간이 12개월 이내인 경우에만 공지예외주장이 가능하다. 반면, 우리나라는 발명의 공개일부터 원출원까지의 기간이 12개월 이내면, 그 이후에도 분할출원을 통해 공지예외주장을 할 수 있다. 아래 그림을 통해 이러한 차이를 시각적으로 나타낸 것이다.

〈그림 1〉 한국과 일본의 분할출원의 공지예외주장시기



나 NK세포 활성화제 사건[52)]

(1) 사실관계

2003년 11월 20일, 원고의 발명은 간행물을 통해 공개되었다. 이후 2003년 12월 12일, 원고는 "NK세포 활성화제" 발명에 대해 기초출원(X)을 진행하였고, 이와 함께 특허청에 공지예외주장 및 증명 서류를 제출하였다. 2004년 7월 9일, 원고는 기초출원(X)을 근거로 특허출원(A)을 하면서 국내우선권을 주장하였다. 그러나, 이 출원(A)에서는 공지예외적용을 위한 취지기재 및 증명서류를 제출하지 않았다. 2010년 10월 13일, 원고는 출원(A)의 분할출원으로 원출원을 하였고, 이후 2013년 3월 18일, 원출원의 분할출원으로 본건 출원을 하게 되었다.

원고는 본건에 대해 2015년 2월 23일자 거절결정을 받고, 같은 해 6월 3일

52) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

거절결정 불복심판 청구를 하였으며, 특허청구범위를 보정하는 절차보정을 진행하였다. 이후 2016년 7월 26일에 다시 특허청구범위를 보정하는 절차보정을 하였다. 특허청은 2016년 11월 22일, "본건 심판 청구는 성립하지 않는다."는 심결을 내렸고, 그 등본은 같은 해 12월 2일 원고에게 송달되었다.

(2) 쟁점

본 판결의 쟁점은 국내우선권 주장이 있는 특허출원이, 기초출원에서 특허법 제30조 제4항에 따른 공지예외적용의 절차를 밟았지만, 우선권 주장 특허출원에서 동일한 절차를 밟지 않았을 때 분할출원에서 제30조 제1항의 공지예외적용을 받을 수 있는지 여부이다.

(3) 양당사자 주장

원고는 기초출원 X에서 신규성 상실의 예외를 주장했기 때문에, 동일한 발명에 대한 분할출원인 본건 출원에도 신규성 상실의 예외가 적용되어야 한다고 주장하였다. 반면, 피고는 본건 출원이 기초출원 X와 독립적인 별개의 출원으로서, 공지예외적용을 위해서는 본건 출원 자체에 대해 별도의 예외 신청이 필요하다고 반박하였다. 피고는 본건 출원에서 해당 절차를 수행하지 않았으므로, 공지예외적용을 인정할 수 없다고 주장하였다.

(4) 하급심 법원의 판단:

(가) 공지예외제도의 절차적 요건이 충족되지 않으면 공지예외적용을 받을 수 없다.

특허법 제30조 제4항은 공지예외제도의 절차에 관한 규정으로, 특허출원과 동시에 공지예외를 주장하는 취지를 기재한 서면을 제출하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다고 규정하고 있다. 공지예외제도의 취지는 신규성 상실의 원칙을 그대로 적용할 경우 발명자에게 불리한 결과를 초래하게 되며, 산업발전을 목적으로 하는 법의 취지에 부합하지 않을 수 있어, 이 원칙에 대한 예외를 인정하는 조치로써 마련된 것이다. 그 예외에 대한 조건으로 제30조 제4항에 따른 절차 요건을 충족해야 한다. 따라서 제30조 제4항의 소정 절차를 이행하지 않은

경우, 신규성 상실의 원칙에 대한 예외인 제1항부터 제3항의 구제 조치를 받을 수 없고, 특허출원 시 제4항의 절차를 전혀 이행하지 않았음에도 이를 추후 보완하여 제1항부터 제3항의 적용을 받을 수는 없다.[53)]

또한, 2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항은 우선권 주장을 포함하는 특허출원이 선출원의 시점에 이루어진 것으로 본다고 규정하고 있으나, 제30조 제4항의 절차가 기초출원 시에 이루어진 것으로 간주된다는 내용은 포함하지 않는다. 따라서, 원고는 출원 A에 대해 제30조 제4항의 "그 취지를 기재한 서면"을 제출하지 않았으므로, 제30조 제1항의 적용을 받을 수 없다.

(나) 원출원 시 공지예외주장을 하지 않으면 분할출원에서는 공지예외적용을 받을 수 없다.

일본 특허법 제44조에 따르면, 원출원 시 특허법 제30조 제4항에 따른 공지예외 규정의 절차에 따라 취지를 기재한 서면 및 증명서류를 제출한 경우, 분할출원에 대해서는 해당 서류들이 분할출원과 동시에 특허청장에게 제출된 것으로 간주된다. 그러나 본 사건에서는 원출원 시 제30조 제4항의 취지를 기재한 서면이 제출되지 않았기 때문에, 원출원 A의 일부를 분할하여 출원한 본건 출원은 제30조 제1항의 규정을 받을 수 없다고 판단하였다.

(5) 지적재산고등법원의 판단

법원은 특허법 제30조 제4항의 적용 범위를 출원 단위로 판단해야 하며, 개별 발명 단위로는 적용될 수 없다고 판시하였다. 이에 따라, 본건 출원에서 공지예외를 적용받기 위해서는 별도의 공지예외주장이 필요하다는 결론을 내렸다. 최종적으로 원고의 청구를 기각하여, 본건 출원에 대한 법적 분쟁을 종결지었다. 법원은 판단 근거는 다음과 같은 사항들로 구성된다,

(가) 공지예외제도의 절차적 요건을 면제하는 특별한 규정이 없는 한, 절차적 요건에 따라야 한다.

특허법 제30조 제4항은 특허법 제30조 제1항의 적용을 위한 절차적 요건으로, 특정 종류의 특허출원(예를 들어, 우선권 주장이 있다.)을 절차의 적용 대상에

53) 도쿄지방법원, 2001년 (행우) 제284호, 2002년 5월 22일 판결.

서 제외하는 예외는 존재하지 않는다. 또한 국내우선권 주장 출원은 기초 출원과는 별도로 독립된 특허출원임이 명백하다. 따라서 국내우선권 주장 출원에 대해서 특허법 제30조 제4항의 적용을 제외하거나 절차적 요건을 면제하는 특별한 규정이 없는 한, 특허법 제30조 제3항의 절차적 요건에 따라 정해진 기간 내에 취지 기재 및 증명서류를 제출해야 한다. 또한 기초 출원에서 제출한 제30조 제4항 서면 및 증명서를 제출한 것으로 이를 대체할 수 없다고 해야 한다.

분할출원의 경우에는 특허법 제44조 제4항이 원출원에 대해 제출된 제30조 제4항의 취지기재 및 증명서는 분할출원과 동시에 특허청 장관에게 제출된 것으로 본다는 취지를 정하고 있으나 국내우선권 주장 출원은 이러한 규정이 없다.

본건은 출원 A의 분할출원인 본건의 원출원을 다시 분할출원한 것으로, 분할출원에 대해서는 원출원에서 제출된 제30조 제4항 서면 및 동일 조 제4항 증명서는 분할출원과 동시에 특허청 장관에게 제출된 것으로 본다는 규정이 있지만, 원고는 출원 A에서 그 출원과 동시에 제4항 서면을 특허청 장관에게 제출하지 않았으므로, 본건은 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항의 적용을 받을 수 없다.

(나) 특허법 제30조의 "특허출원"은 기초출원을 의미한다.

2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항의 문언 및 동일 항의 취지에 비추어, 동일 항은 국내우선권 주장 출원에 관련된 발명 중 기초 출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해, 특허법 제29조를 적용할 때, 동일 조 중의 "특허출원 전"에 해당하는 "특허출원"은 기초 출원 시에 이루어진 것으로 보고, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항을 적용할 때는, 동일 항 중의 "그에 해당하게 된 날로부터 6개월 이내에 그 자가 한 출원"에 해당하는 "특허출원"은 기초출원 시에 이루어진 것으로 본다는 취지를 규정한 것이며, 신규성 상실의 예외 규정(동법 제30조 제1항)과 신규성·진보성에 관한 규정(동법 제29조)을 일체로 취급해야 한다는 것은, 2004년 개정 전 특허법 제41조 제2항의 문언상뿐만 아니라, 그 취지로부터도 도출할 수 없다.

(다) 절차적 요건이 정해져 있지 않다고 해서 절차의 이행이 불필요한 것은 아니다.

2004년 개정 전 특허법 제41조 제4항에 2011년 개정 전 특허법 제30조 제4항

과 같은 절차가 정해져 있지 않다고 하여, 국내우선권 주장 출원에 관련된 발명 중 기초출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명에 대해, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제1항이 적용되는 절차적 요건으로서, 국내우선권 주장 출원에서 동일 조 제4항에 정해진 절차를 이행하는 것이 불필요하다고 할 수 없다.

또한, 특허법 제29조의 적용에는 특별한 절차적 요건이 없으므로, 2011년 개정 전 특허법 제30조 제4항에 정해진 절차의 이행을 절차적 요건으로 하는 동일 조 제1항의 적용과 동일하게 논할 수는 없다.

5 긍정론과 부정론 비교 및 분석

이로써 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았을 경우, 분할출원 단계에서 공지예외 주장이 가능한지 여부를 쟁점으로 한 국내 판례인 변전시스템 학술대회 사건(대법원 2010후2353 판결)과 석사학위논문 분할출원 사건(대법원 2020후11479 판결)을 분석하였다. 아울러, 유사한 제도를 운용하는 일본에서 공지예외와 관련된 판례인 NK세포 활성화제 사건(지적재산고등법원 2017년 (행케) 제10279호 판결)을 검토하였다. 본 장에서는 이러한 국내 및 일본 판례를 바탕으로 긍정론과 부정론으로 나뉜 주요 논거를 비교하고, 각 입장에 대한 비판적 분석을 통해 쟁점에 대한 보다 심층적인 논의를 전개하고자 한다.

가 긍정론

(1) 특허법 제30조의 취지

분할출원 시에도 공지예외주장이 가능하다는 긍정론은, 특허법 제30조의 취지가 자유로운 연구 활동을 촉진하는 데 있으므로, 분할출원에서도 공지예외주장을 허용해야 한다고 주장한다.[54] 또한 특허법 제30조에서 규정하는 공지예외제도는 거듭된 개정으로 요건을 완화하고 발명 보호의 실효성을 확보하고 있으므로 분할

54) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결.

출원 시에도 공지예외적용을 위한 취지 기재 보정이 허용되어야 한다고 주장한다.[55] 학설에서는 공지예외제도에 대한 긍정적 입장은 우리나라에서 공중의 이익보다 발명자의 권리 보호를 중시하는 방향으로 법적 균형점이 설정되었으며, 이를 통해 발명자의 권리를 실효적으로 보호하려는 입법적 결단이 이루어졌다고 본다.[56] 그러나 공지예외제도의 운영 여부는 발명자 보호와 제3자에게 미치는 영향을 균형적으로 고려한 입법자의 결단에 따른 것이며, 공지예외제도를 어느 정도로 엄격하게 또는 관대하게 운영할 것인지는 입법자의 결단사항이다. 따라서 법원은 이러한 입법 취지에 맞춰 해석해야 한다. 공지예외제도를 발명자 보호에 지나치게 치중하여 해석하는 것은 균형 잡힌 해석으로 보기 어렵다.

(2) 분할출원의 공지예외제도에 대한 명시적 규정의 부재

긍정론은 분할출원 시 공지예외주장시기에 대한 명시적 규정이 없고, 공지예외 기재의 누락은 절차상 형식적인 하자에 불과하므로 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있다고 본다.[57] 그러나 이러한 긍정론은 제도적 허점을 남용하여 공지예외제도의 취지와 목적에 반하는 편법적 해석이다. 법적 절차는 모든 이례적인 경우를 완벽히 대비할 수 없으나, 제도적 허점을 통해 이익을 얻으려는 임의적인 해석은 공정성을 저해할 수 있다. 입법자는 발명 공개 후 1년 이내에 공지예외주장을 하도록 기한을 명시하였는데, 대상 판결은 이러한 규정을 허점(loophole)을 통해 무력화시켜 그 1년의 기한을 의미 없게

55) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결("2006. 3. 3. 법률 제7871호 개정법은 공개 형태를 특정한 경우로 한정하는 제한을 없애고 모든 형태의 자발적 공개 행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 함으로써 자기 공지에 의한 공지예외 규정의 실질적 실효성을 확보하였고").

56) 김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면("공지예외적용의 범위와 요건 등은 각 국가의 입법정책의 문제로 볼 수 있을 것인데, 이미 우리나라에서는 공중의 이익과 발명자로서의 이익의 균형점을 좀 더 발명자로서의 권리를 보호하는 편으로 이동시켜서 발명자의 권리를 좀 더 실효적으로 보 호하기로 '입법적인 결단'을 내린 것으로 평가할 수 있다."); 이주환, "특허법상 분할출원의 공지예외주장 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -", 2022 TOP10 특허판례 세미나, 한국특허법학회, 2022, 137면.

57) 특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결; 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결; 김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 31-32면.

만든다. 즉, 대상 판결은 입법자가 정한 1년 기한의 절차적 의미를 퇴색시키는 결과를 초래한다. 따라서 1년이 경과한 후의 분할출원에서 새로운 주장을 허용하지 않아야 한다는 명확하고 강력한 논리적 근거가 존재한다고 본다.

(3) 특허법 제52조 제2항 규정의 해석

긍정론에서 대법원 판결은"특허법 제52조 제2항은 적법한 분할출원이 있을 경우 원출원일에 출원한 것으로 본다는 원칙과 그 예외로서 특허법 제30조 제2항의 공지예외주장의 제출 시기, 증명서류의 제출 기간에 관하여는 분할출원일을 기준으로 한다"고 정하고 있을 뿐, 공지예외주장을 원출원이 아닌 분할출원에서만 한 경우, 요건 충족 여부에 대해 원출원일을 기준으로 정하고 있지 않다는 점을 논거로 제시하였다.[58)]

특허법 제52조 제2항은 분할출원에 대하여 제30조 제2항을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다고 규정한다. 그 규정은 분할출원 시에 공지예외의 주장을 허용하는 명문의 규정이다. 공지예외를 주장한 원출원에 기초한 분할출원이 있는 경우, 두 가지 처리방안이 제시된다. 하나는 원출원이 이미 공지예외를 주장하였으므로, 분할출원에서는 굳이 공지예외를 주장할 필요가 없게 하는 방안이다. 다른 하나는 원출원이 공지예외를 주장하였음에도 불구하고 분할출원에서 새롭게 공지예외를 주장하게 하는 방안이다. 두 방안 모두 장단점이 있을 것이나, 우리 특허법 제52조 제2항은 후자의 방안을 채택하여, 분할출원의 경우 공지예외 주장 및 증명서류 제출 기한의 기산점을 분할출원의 출원일로 명확히 규정하고 있다. 결론적으로, 우리 특허법 제52조 제2항은 분할출원 시에 공지예외의 주장을 새롭게 하도록 강요하는 것으로 이해하는 것이 타당하다.

원출원이 1년 이내에 출원되었고 공지예외가 적법하게 주장된 경우, 분할출원 시 원출원의 공지예외 주장을 연결하기 위해서는 공지예외를 새롭게 주장해야 한다. 원출원에서 공지예외를 주장하지 않았더라도, 분할출원이 1년 이내에 출원된

58) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결("원출원에서 공지예외주장을 하지 않고 분할출원에서만 공지예외주장을 한 경우에는 분할출원일을 기준으로 공지예외 주장의 요건 충족 여부를 판단하여야 한다거나 원출원에서의 공지예외주장을 분할출원 에서의 공지예외주장을 통한 원출원일을 기준으로 한 공지예외의 효과 인정 요건으로 정하고 있지 않다.").

경우에는 새롭게 공지예외주장을 할 수 있을 것이다. 이와 같은 해석을 따른 판례로, 일본의 NK세포 활성화제 사건에서는 원출원에서 적법하게 공지예외를 주장했더라도 분할출원에서 이를 새롭게 주장해야 한다고 판시하였다.[59] 우리나라 특허법 제52조 제2항 역시 이러한 판결의 내용을 조문화하여, 후자의 방안을 채택했음을 명확히 보여주는 것으로 해석하는 것이 타당하다.

(4) 분할출원의 공지예외적용에서의 기준시점은 분할출원일이다.

긍정론은 분할출원일을 기준으로 공지예외적용이 가능하다고 본다. 이는 공지예외주장이 원출원이 아닌 분할출원에서만 이루어진 경우, 요건 충족 여부를 판단할 기준이 원출원일로 명확히 정해져 있지 않다는 점을 이유로 한다.[60] 또한 분할출원의 공지예외제도는 분할출원일이 그 기준이 되어야 한다고 본다. 따라서 긍정론에 따르면, 공지일부터 원출원일까지 12개월 이내에 출원했다면, 12개월이 경과하더라도 분할출원 시 공지예외 주장을 할 수 있다고 본다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 일본의 특허심사실무에서는 공지일부터 분할출원일까지의 기간을 12개월로 제한하고 있는 반면, 우리나라 실무는 원출원일을 기준으로 판단하고 있다. 원출원일을 기준으로 공지예외기간을 설정하면서도 분할출원의 공지예외주장이 분할출원일을 기준으로 해야 한다는 긍정론의 논리는 모순이다. 분할출원의 공지예외 적용이 분할출원일을 기준으로 이루어지려면, 일본처럼 공지일부터 분할출원일까지의 기간을 공지예외기간으로 설정하는 제도적 근거가 우선적으로 마련되어야 한다.

(5) 공지예외제도의 완화 추세

긍정론에서는 국내 및 주요국의 공지예외제도가 공개의 범위뿐만 아니라 그 기간과 절차 요건까지 계속해서 완화하고 있으며, 특허제도에 미숙한 발명자에 대한 보호를 넘어 실효적인 보호 제도로 자리매김 하고 있다고 주장한다.[61] 공지예외제

59) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

60) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

61) 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결("공지예외 규정은 특허법 제정 이후 현재에 이르기까지 그 예외 인정 사유가 확대되고, 신규성뿐만 아니라 진보성과 관련해서도 이를 적용하며, 그 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다"); 김관식, "특허출원

도는 역사적으로 살펴보면 계속해서 완화되고 있는 추세인 것은 맞으나, 해당 출원에 적용되는 그 당시의 법의 규정이 적용되어야 하는 것이다. 분할출원의 공지예외제도는 현재 법으로 규정된 것이 없는 바, 적용되지 않는 미래의 법의 규정이 해당 출원에 적용되어서는 아니 된다. 공지예외제도는 역사적으로 그 적용 범위가 점차 확대되고 완화되어 온 것은 사실이다.[62] 그러나 유럽은 과거부터 현재까지 계속하여 엄격한 제도를 운영하고 있다. 이러한 점을 감안하면 미래에도 더 완화할 것인지에 대하여는 단정할 수 없다. 또한 우리나라와 가장 유사한 제도를 채택하고 있는 일본에서도 공지일로부터 1년이 경과한 경우에는 분할출원의 공지예외적용을 허용하지 않고 있다. 따라서 각 출원에 대해서는 그 출원 시점에 적용되는 법 규정에 따라 판단해야 한다. 현재 특허법상 분할출원에 대한 공지예외규정은 특허법 제52조 제2항에서 공지예외주장시기를 분할출원일에 한 것으로 본다는 것을 제외하고 별도로 명시되어 있지 않으므로, 규정되지 않은 법규나 완화된 조건을 해당 출원에 적용할 수는 없다고 보아야 한다.[63]

(6) 원출원 시 미처 권리화하지 못한 발명이 분할출원 시 공지되는 경우

대법원은 원출원 당시 청구범위가 공지된 내용과 무관하여 공지예외주장을 하지 않았더라도, 분할출원 시 청구범위에 공지된 내용이 포함될 수 있다는 점을 고려하여 긍정론을 주장하였다.[64] 대법원은 이러한 경우를 보호하기 위해, 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 이를 인정할 실질적 필요성이 있다고 판단하였다. 그러나 원출원에 포함되지 않았던 내용이 분할출원에서 새롭게 추가

당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면.

62) 김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 30면("공지예외적용의 범위와 요건 등은 각 국가의 입법정책의 문제로 볼 수 있을 것인데, 이미 우리나라에서는 공중의 이익과 발명자로서의 이익의 균형점을 좀 더 발명자로서의 권리를 보호하는 편으로 이동시켜서 발명자의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기로 '입법적인 결단'을 내린 것으로 평가할 수 있다.").

63) 특허법 제52조 제2항("제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.").

64) 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결.

될 수는 없다. 신규사항의 도입이 금지되기 때문에, 원출원의 명세서나 도면에 기재되지 않은 새로운 발명을 분할출원에 포함시키는 것은 허용되지 않는다.[65] 따라서 이러한 신규사항의 도입은 특허법상 허용되지 않으며, 분할출원에서 새로운 내용을 추가하는 것은 원출원의 범위를 벗어나므로 법적으로 인정될 수 없다.

나 부정론

(1) 특허법 제52조 분할출원의 입법취지

부정론은 분할출원의 입법 취지가 공지예외주장시기를 누락한 것을 회피하기 위한 수단이 아니라고 본다.[66] 분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로, 원출원의 절차적 효력이 분할출원에 자동으로 승계되지 않으며, 분할출원에서도 별도로 공지예외 주장을 해야 한다는 것이다.[67] 특허법 제52조 제2항은 분할출원에 공지예외를 적용할 경우, 분할출원을 한 시점을 출원일로 간주한다고 규정하고 있다. 이는 원출원에서 공지예외를 주장한 경우 분할출원 시 이를 재차 주장할 수 없게 되는 문제를 해결하기 위한 것이며, 원출원에서 공지예외 주장의 기재를 누락한 것을 보완하기 위한 수단이 아니다.

분할출원의 공지예외는 일반적인 신규성 법리에 대한 '예외'에 해당하므로, 법에서 규정한 절차와 조건을 엄격히 준수해야 하며, 이를 해석으로 완화하여 적용할 수 없다. 특히 원출원 시 공지예외주장을 하지 않는 경우, 분할출원에서 공지예외주장을 통해 법의 요건을 회피하려는 시도는 특허법 제30조의 입법 취지에 반한다고 볼 수 있다. 따라서 원출원에서 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 이를 새로이 주장하는 것은 입법 목적에 어긋나므로 인정될 수 없다. 법에서 정한

65) 특허청, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 2023년, 6105면("분할출원할 수 있는 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내이다. 이때, 분할출원의 명세서 또는 도 면에 기재된 발명 모두는 원출원의 명세서 또는 도면에 포함되어야 하며, 분 할출원의 발명 중 일부라도 원출원에 포함되어 있지 않은 경우에는 그 분할 출원은 부적법하거나 거절이유를 갖는 것으로 취급된다.[특법52(1)]").

66) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허 3072 판결.

67) 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결은 공지예외제도는 출원과 별개의 절차이므로, 출원 시 공지예외주장을 하지 않은 출원은 통상의 출원으로 간주되어 공지예외 적용을 받을 수 없다고 보았다.

절차적 요건을 우회하거나 완화하려는 해석은 해당 규정의 기본적인 법리와 균형을 훼손하는 결과를 초래할 수 있다.

(2) 형해화 우려

특허법 제30조 제3항이 신설되었음에도 분할출원을 통해 공지예외의 주장 시기에 대한 규정을 우회할 수 있다면, 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 것을 분할출원으로 보완하게 되어 특허법 제30조 제2항의 규정을 형해화할 우려가 있다.[68] 특허법 제52조 제2항은 절차적 요건에 대한 예외를 두기 위한 조항이 아니라, 분할출원 시에도 새롭게 공지예외의 취지 주장 및 증명서류 제출이 필요하다는 점을 명확히 하기 위한 제도이다. 또한 특허법 제30조 제3항은 공지예외주장시기를 보완하기 위해 마련된 제도로, 이 규정의 목적은 해당 절차를 엄격히 이행하도록 요구하는 데 있다. 따라서 분할출원을 통해 이러한 규정을 무력화하는 것은 제도의 취지를 훼손하고, 제도 운영의 허점을 악용할 수 있도록 방치하는 결과를 초래할 수 있다.

(3) 분할출원의 공지예외적용에서의 기준시점은 원출원일이다.

분할출원의 공지예외주장시기에 대해 부정론은 원출원일을 기준일로 보며, 특허법 제30조에서 규정한 "공지일로부터 12개월 이내의 특허출원"이 기초출원인 원출원을 의미한다고 해석한다.[69] 일본에서는 공지일로부터 분할출원일까지의 기간이 12개월 이내일 때만 공지예외를 인정하고 있으며, 이는 공지일로부터 12개월 이내에 원출원만 하면 공지예외를 인정하는 우리나라보다 더 엄격하게 운영되고 있다. 일본의 공지예외 제도를 규정하는 특허법 제30조와 분할출원을 규정하는 제44조의 조문은 우리나라와 유사하지만, 일본은 분할출원의 공지예외적용 시점을 기초출원일로 보고 있다는 점에서 차이가 있다. 유사한 법제를 따르는 일본이 공지일로부터 12개월이 지난 분할출원을 인정하지 않는 점을 고려할 때, 공지일로부터 12개월 이내에 원출원만 하면 분할출원에서 공지예외 주장 시기를 무력화하는 해석은 발명자에게 지나치게 유리한 결과를 초래할 수 있다.

68) 특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결.

69) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

(4) 공지예외적용을 위해서는 절차적 요건을 충족해야 한다.

특허법 제30조의 규정은 공지예외적용을 위한 절차적 요건으로, 특정 종류의 특허출원을 절차의 적용 대상에서 제외하는 예외는 존재하지 않는다. 따라서 분할출원의 공지예외적용은 주장시기 및 절차를 규정하는 특허법 제30조 제2항 및 공지예외주장시기의 보완규정인 제30조 제3항, 분할출원의 공지예외적용에 대한 제52조 제2항 제2호에서 절차적 요건을 면제하는 규정이 없으므로, 특허법 제30조의 절차적 요건에 따라 정해진 기간 내에 취지 기재 및 증명서류를 제출해야 한다.[70]

다 소결

앞서 검토한 긍정론과 부정론은 원출원시 공지예외주장을 하지 않았을 때 분할출원에서 공지예외제도의 적용 가능성과 그 한계를 둘러싼 주요 쟁점에 대해 상반된 입장을 보여준다. 긍정론은 발명자의 권리 보호와 제도적 취지를 중시하여 분할출원에서 공지예외주장을 허용해야 한다는 입장을 견지하는 반면, 부정론은 입법취지와 절차적 요건의 엄격한 준수를 강조하며 이를 제한적으로 해석해야 한다고 본다. 본 소결에서는 양측 입장을 바탕으로 분할출원에서의 공지예외제도에 대한 긍정론을 반박하고, 이를 통해 논문의 결론으로 이어질 논거를 제시하고자 한다. 먼저 변전시스템 학술대회 사건과 석사학위논문 사건의 긍정론과 부정론을 비교하면 아래의 표와 같다.

〈표2〉 판례에서의 긍정론과 부정론 비교

사건 구분	법원 구분	긍정론	부정론
변전시스템 학술대회 사건	특허법원	① 절차적 요건에 불과하므로 발명자 보호, 기술발전 촉진을 위해 출원 후 보정이 허용되어야 함 ② 의사공개에 대해 반의사공개와 차별하여 출원시에만 요건을 준수하도록 요구하는 것은 형평	해당 없음

70) 일본 지적재산고등법원, 심결취소청구 사건 특허권 행정 소송, 2017년 (행케) 제10279호, 2017년 11월 30일 판결.

		성에 어긋남 ③ 해당 절차는 출원시 반드시 구비되어야 하는 것이 아님 ④ 특허법령에서 출원 후 절차적 요건의 준수를 위한 보정을 명시적으로 금지하지 않고 있음	
	대법원	해당 없음	① 공지예외적용을 주장하는 것은 출원과는 별개의 절차
석사학위 논문 사건	특허법원	해당 없음	① 분할출원의 입법취지는 공지예외적용을 위한 회피수단이 아님 ② 특허법 제30조 제2항 규정의 형해화 우려 ③ 특허법 제30조 제3항의 취지는 분할출원의 공지예외적용에 대한 허용이 아님
	대법원	① 제52조 제2항이 분할출원의 경우 분할출원일을 기준으로 절차적 요건을 준수하는 것을 허용함 ② 분할출원에서 새로이 공지예외를 주장할 경우가 있으므로 허용하여야 함 ③ 제30조 제2항을 형해화 할 우려는 근거가 없는 것임 ④ 분할출원의 공지예외주장과 제30조 제3항의 신설은 별개의 제도임 ⑤ 공지예외제도는 발명자 보호를 위한 제도임	해당 없음

위에서 특허법원이 변전시스템 학술대회 사건에서 제시한 긍정론의 논거는 석사학위논문 사건에서의 대법원 판결에서 거론되지 않았다. 달리 말하면, 특허법원이 변전시스템 학술대회 사건에서 제시한 긍정론의 논거는 대법원에서 채택(인용)되지 않은 것이다. 대법원이 채택(인용)하지 않은 이유를 별도로 제시하지 않았으나, 필자는 다음과 같은 이유가 그 불채택의 이유일 것이라고 생각한다.

〈표3〉 변전시스템 학술대회 사건에서의 특허법원의 논거에 대한 반박

긍정론	반박
① 절차적 요건에 불과하므로 발명자 보호, 기술발전 촉진을 위해 출원 후 보정이 허용되어야 함	공지예외제도는 제29조가 규정하는 일반적인 공지법리에 대해 '예외'를 인정하는 제도이다. 예외를 인정하는 제도라는 점을 감안하여 입법부는 제30조가 규정하는 절차적 요건을 준수하는 것을 전제로 공지예외를 인정한다. 제30조가 규정하는 절차적 요건은 한편으로는 발명자 보호 및 기술발전 촉진이라는 측면과 다른 한편으로는 제3자 보호라는 측면을 종합적으로 고려한 후의 요건이다.
② 의사공개에 대해 반의사공개와 차별하여 출원시에만 요건을 준수하도록 요구하는 것은 형평성에 어긋남	의사공개에 대한 절차적 요건과 반의사공개에 대한 절차적 요건을 동일하게 할 것인지 다르게 할 것인지는 입법자가 결단할 사항이다. 공지예외제도를 운영하는 대부분의 국가들이 두 공개에 대해 절차적 요건을 달리 책정하고 있다.
③ 해당 절차는 출원시 반드시 구비되어야 하는 것이 아님	제30조 제2항은 출원시 취지서면을 제출하고, 30일 이내에 증명서류를 제출할 것을 요구한다. 법규정의 명확한 문언이 그대로 해석, 적용되어야 한다.
④ 특허법령에서 출원 후 절차적 요건의 준수를 위한 보정을 명시적으로 금지하지 않고 있음	공지예외제도는 제29조가 규정하는 일반적인 공지법리에 대해 '예외'를 인정하는 제도이다. 그러므로, 그러한 예외는 명시적인 법규정에 의해서만 인정되어야 한다. 명시적 규정이 없으므로 허용되어야 하는 것이 아니라, 명시적 규정이 없으므로 허용되지 않아야 하는 것이다. 공개로부터 1년 이내 출원 및 출원시 취지서면 제출, 30일 내 증명서류 제출이라는 명확한 규정이 있으므로 그 규정이 지켜져야 한다.

대법원 2020후11479 판결(석사학위논문 사건)은 김관식 교수의 논문(2022)[71]의 긍정론이 직접적인 영향을 미쳤을 가능성이 높다. 이 논문의 초안은 2022년 4월에 대법원에서 개최된 '제255차 특별소송실무연구회'에서 발표되었고, 대법원 판결 이전인 2022년 6월에 발간되었다.[72] 또한 김관식 교수가 과거 대법원 재판연구관(지식재산조)으로 역임했던 점을 고려하면, 그의 연구가 해당 대법원 판결에

71) 김관식, "특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-", 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.

72) 김관식, 앞의 논문, 3면 각주.

중요한 영향을 미쳤을 가능성이 크다고 볼 수 있다. 김관식은 우리나라와 주요국 공지예외제도의 입법적 완화가 진행되고 있는 연혁을 고려할 때 분할출원의 공지예외주장은 허용되어야 한다고 주장하였다.[73] 그러나 이러한 주장은 앞서 일본의 판례를 통해 반박하였으며, 지금까지 일부 완화가 이루어진 것은 사실이지만, 유럽이 여전히 엄격한 제도를 고수하고 있는 점을 고려할 때, 향후 더 완화될지에 대해서는 확실하게 예측할 수 없다.

또한 대상 출원의 개정 사항과 법적 배경을 비교하여 해당 쟁점의 타당성을 도출할 수 있다. 대상 출원의 출원일은 2014년 12월 23일이며, 출원번호는 제10-2014-186799호이다. 당시 적용된 구 특허법(제12753호로 개정되기 전의 법)은 공지예외제도의 절차적 요건에 있어 현재의 요건과 일부 차이가 있었다. 이를 살펴보면, 2015년 1월 28일 개정된 특허법 제30조 제3항의 신설로 인해 출원 시 공지예외주장을 하지 않았더라도, 보완수수료를 납부한 경우 보정기간 또는 특허결정 등본 송달일로부터 3개월 이내에 공지예외주장이 가능하도록 요건이 완화되었다.

〈표4〉 공지예외제도 절차적 요건의 변화

구분	구 특허법 (법률 제12753호로 2014. 6. 11. 개정되기 전의 법)[74]	개정 특허법 (법률 제13096호, 2015. 1. 28. 일부개정)
주장시기	출원 시 취지 기재	출원 시 취지 기재
		보완수수료를 납부한 경우 보정기간 또는 특허결정 등본 송달받은 날부터 3개월(단, 설정등록 이전) 이내
증명서류	출원일부터 30일 이내	출원일부터 30일 이내

73) 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 38면(“원출원에서 공지예외 주장을 하였는지 여부에 관계없이 가능하다고 보는 것이 특허법 관련 규정의 해석 및 특허법 개정 연혁의 취지에 부합하고 나아가 선출원주의 하에서 발명을 출원 전에 공개한 발명자의 권리를 일정 한도 내에서 실효적으로 보호하여 산업발전이라는 특허법 목적의 구현에도 기여할 수 있을 것으로 생각된다.”).

74) 출원일이 2014년 12월 23일인 대상 출원에는 구 특허법(법률 제12753호, 2015. 1. 1. 시행 전)이

그러나 대상 출원은 2013년 7월 30일 개정된 구 특허법의 적용을 받았으므로, 공지예외주장시기를 연장할 수 있는 제도가 존재하지 않았다. 이에 따라 해당 출원인은 분할출원을 통해 공지예외주장을 새롭게 하는 방식을 선택한 것으로 보인다. 하지만 출원 시 공지예외주장을 누락했음에도 불구하고, 이를 분할출원을 통해 보완하는 것은 특허법 제30조 제2항 및 새롭게 도입된 제3항의 입법 취지를 훼손할 우려가 있다. 이러한 방식은 공지예외제도의 절차적 요건을 형해화하고, 출원인이 지켜야 할 절차적 의무를 무시하는 결과를 초래할 수 있다.

6 결 론

가 공지예외와 분할출원의 법적 쟁점 재해석

특허법 제30조는 특허출원 전에 발명을 공개한 발명자를 보호하기 위해 공지예외제도를 규정한다. 공지예외의 적용을 받기 위해서는 제30조 제2항이 규정하는 주장시기를 준수하는 것이 원칙이나, 원출원에서 그 시기를 놓친 경우 분할출원에서 새롭게 공지예외를 주장할 수 있는지에 대해 상반된 판결들이 존재한다. 본 논문은 공지예외제도와 분할출원제도의 법리적 문제를 검토하고, 관련 판례와 일본 사례의 분석을 진행하였다.

먼저 특허법 제30조의 공지예외제도와 제52조의 분할출원제도를 검토하여 분할출원의 공지예외적용에 대한 쟁점을 도출하였다. 특허법에는 분할출원 시 공지예외 적용에 대한 명시적 규정이 없으며, 특허 심사실무에서는 원출원에서 공지예외의 주장을 하지 않았더라도 분할출원에서의 새로운 주장을 허용하고 있으나, 이에 대한 법리적 근거는 미흡하다. 판례에서도 그 허용 여부에 대한 상반된 입장이 존재한다. 변전시스템 학술대회 사건에서는 공지예외주장시기가 도과하여 취지 기재 및 증명서류를 제출하는 경우에 대해, 하급심은 공지예외의

적용되었다.

적용을 인정한 반면, 특허법원은 이를 부정하였다. 반면, 석사학위논문 사건에서는 원출원 시 공지예외주장을 하지 않은 경우, 분할출원에서 이를 주장할 수 있는지에 대해 하급심은 부정하였으나, 대상 판결은 인정하였다. 본 논문에서는 부정한 논거 및 긍정한 논거를 각 부정론과 긍정론으로 나누어 분석하고, 우리나라와 유사한 제도를 운영하는 일본의 제도와 판례를 비교하였다. 그 결과, 대상 판결이 채택한 근거가 타당하지 않음을 논증하였다.

판례의 논거는 공지예외제도의 취지, 절차, 기준일에 대한 관점에 따라 상반된 견해로 나눌 수 있다. 특허법 제30조와 제52조의 취지에 따른 부정론은 분할출원이 원출원에서 공지예외 주장을 하지 못한 것을 보완하는 수단으로 악용되어서는 안 된다고 본다. 반면, 긍정론은 공지예외제도의 목적이 발명자 보호와 연구활동 촉진에 있으므로, 분할출원 시에도 공지예외 주장을 허용해야 한다고 본다. 또한 분할출원과 공지예외제도는 별개의 제도로, 분할출원의 공지예외 적용은 공지예외제도의 취지에 맞춰 해석해야 한다고 주장한다.

절차적 관점에서 부정론은 공지예외와 출원 절차가 별개이므로, 공지예외를 주장하지 않은 출원은 통상의 출원으로 간주되어 공지예외 주장 시기가 아닌 때에 이를 주장할 수 없다고 본다. 이러한 절차를 따르지 않으면 제도의 형해화가 발생할 수 있으므로, 정해진 절차를 준수해야 한다는 입장이다. 반면 긍정론은 공지예외 취지 기재의 누락이 절차상 형식적인 하자에 불과하며, 이에 대한 명시적 규정이 없기 때문에 원출원 시 공지예외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 이를 주장할 수 있다고 본다. 부정론의 제도의 형해화에 대한 우려는 근거가 부족하다고 비판한다.

공지예외의 기준일에 대해서도 견해가 갈린다. 일본의 부정론은 공지예외제도에서의 특허출원을 분할출원의 기초가 되는 원출원으로 해석한다. 반면, 긍정론은 공지예외의 기준일을 분할출원일로 보아, 원출원에서 공지예외를 주장하지 않았더라도 분할출원 시 이를 주장할 수 있다고 본다. 긍정론은 원출원 시 공개되지 않았던 발명이 분할출원 시 공개되는 경우, 공지예외제도가 완화되는 방향으로 개정되고 있다는 점도 논거로 제시한다.

앞 장에서는 부정론과 긍정론을 분류하여 긍정론의 논거가 타당하지 않음을

논증하였다. 특허법 제30조가 규정하는 절차요건은 반드시 준수되어야 하며, 이를 무력화하는 법 해석은 허용될 수 없다. 절차요건의 예외를 두기 위해서는 특허법 제200조에서 허용하는'특례'와 같은 입법자의 명확한 의도가 반영된 규정이 필요하다.[75] 특허법 제52조 제2항은 제30조의 절차적 요건에 대한 예외를 규정한 것이 아니라, 분할출원 시에도 새롭게 공지예외주장 및 증명서류 제출이 필요함을 명확히 한 것이다.

원출원이 공개일로부터 1년 이내에 출원되었고, 취지서면 및 증명서류를 적법하게 제출한 경우, 그로부터 분할출원되는 경우에도 동일하게 분할출원일로부터 30일 이내에 서류를 제출할 수 있다. 원출원에서 이미 절차적 요건을 충족한 경우, 분할출원에서는 더 이상 요구하지 않을 수도 있으나, 우리 특허법은 추가적으로 요구하고 있다.

반면, 원출원이 공개일로부터 1년 이내에 출원되었으나 공지예외 서류를 제출하지 못한 경우, 그 이후 출원되는 분할출원에는 공지예외가 적용되지 않는다. 입법부가 제30조에서 규정하는 공지예외에 추가적인 예외를 허용하는 것은 명확하지 않으므로, 예외에 대한 추가 예외는 신중하게 인정되어야 한다.

입법부가 제30조에 추가적인 예외를 허용하기 위해서는 특허법 제200조와 같은 명확한 규정이 필요하다. 국제출원의 경우에도 출원일이 공개일로부터 12개월 이내인 경우에만 추가적인 예외를 인정하고 있으며, 공개일로부터 12개월을 경과한 분할출원에 대해 국제출원보다 우호적인 예외를 인정해서는 곤란하다. 이러한 예외는 입법부의 명확한 규정에 의해 가능해야 하며, 사법부의 모호한 법해석에 의해 인정될 수는 없다.

나 국제특허출원의 공지예외제도에 관한 특례(특허법 제200조)

특허법 제200조는 국제특허출원된 발명에 대해 제30조 제1항 제1호의 공지

75) 특허법 제200조("국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 산업통상자원부령으로 정하는 기간에 특허청장에게 제출할 수 있다.").

예외적용을 위한 특례를 규정하고 있다.[76] 본래 공지예외를 적용받기 위해서는 제30조 제2항에 따라 특허출원 시 그 취지를 기재하고, 증명서류를 출원일부터 30일 이내에 제출해야 한다. 그러나 국제특허출원된 발명에 대해서는 제30조 제2항의 요구와 달리, 제200조에 따라 국내서면제출기한의 만료일[77](외국어로 출원한 경우 우선일부터 2년 7개월이 만료되는 날, 출원심사를 청구한 경우에는 청구일) 경과 후 30일까지 취지 및 증명서류를 제출할 수 있다.[78]

〈표5〉 일반출원과 국제출원의 공지예외제도 절차 요건

구분	일반출원	국제출원[79][80]
공지예외기간	1년	1년[81][82]
취지서면 제출	출원시	국내서면제출기간(외국어 출원인 경우 2년 7개월) 후 30일 등[83]
증명서류 제출	출원일로부터 30일	

76) 특허법 제200조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례)("국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 **산업통상자원부령으로 정하는 기간**에 특허청장에게 제출할 수 있다."); "산업통상자원부령으로 정하는 기간"이란 특허법 제111조에서 규정하는 것으로, 특허법 제201조제5항에 따른 기준일 경과후 30일을 말한다.

77) 특허법 제201조 제1항("**국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인**은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 **우선일(이하 "우선일"이라 한다)부터 2년 7개월(이하 "국내서면제출기간"**이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 특허청장에게 제출하여야 한다."); 특허법 제201조 제5항("특허출원인이 **국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 "기준일"이라 한다)**까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 "최종 국어번역문"이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.").

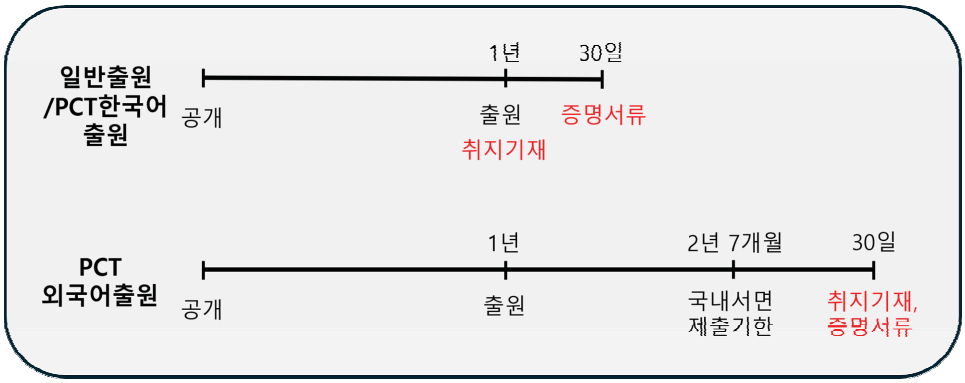
78) 특허법 제111조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 서류제출기간의 특례)("법 제200조에서 "산업통상자원부령이 정하는 기간"이란 법 제201조제5항에 따른 **기준일 경과후 30일**을 말한다.").

79) PCT, Rule 4, 4.17 Declarations Relating to National Requirements Referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (v)("The request may, for the purposes of the national law applicable in one or more designated States, contain one or more of the following declarations, worded as prescribed by the Administrative Instructions: … (v) a declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, as referred to in Rule 51bis.1(a)(v).")〈https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#_4_17〉.

80) 특허청, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 2023년, 3237면.

81) Min Son, "Grace period but no safeguards for missing deadlines in South Korea",

〈그림2〉 일반출원과 국제출원의 공지예외주장시기



국제출원도 공지예외를 주장하기 위해서는 기본적으로 공개일로부터 1년 이내에 출원해야 하며, 외국어로 국제출원한 경우 취지서면과 증명서류의 제출을 국내단계 진입 후 30일까지 연기할 수 있는 예외를 인정한다.[84] 분할출원의 경우에도 공개일로부터 1년 이내에 출원되었다면 그 출원일로부터 30일 이내에 취지서면 및 증명서류를 제출할 수 있다. 이러한 규정은 분할출원에 대해 일반출원보다 더 큰 혜택을 주는 것이 아니다.

ManagingIP, 2021("In order to enjoy the grace period in South Korea, either (i) a PCT application; or (ii) a direct South Korean application must be filed within one year of the earlier 'disclosure' date, not the priority date.") 〈https://www.managingip.com/article/2a5d034hr8td8p0r6kmbk/grace-period-but-no-safeguards-for-missing-deadlines-in-south-korea〉.

82) Allegro, "1 Year Grace Period in Japan – Exceptions to Loss of Novelty", *Allegro*, 2021("In this case, it is necessary to file a PCT international application within 1 year from the disclosure. That is, the international filing date should fall within the 1 year period, neither the priority date nor the Japanese national phase entry.")〈https://allegropat.com/grace-period/〉.

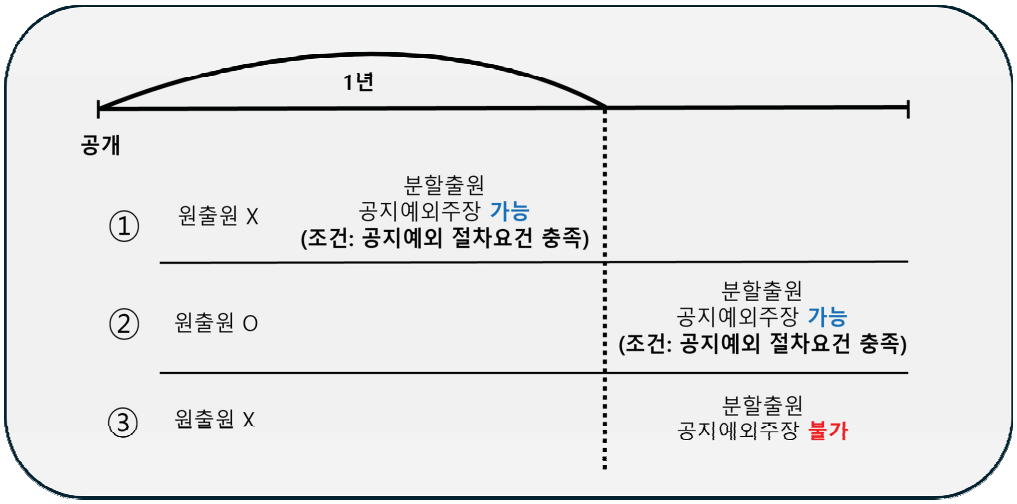
83) 동 기한보다 심사청구가 먼저 되는 경우 심사청구일.

84) 특허청, "특허·실용신안 심사기준", 특허청 예규 131호, 2023년, 3237면("한편, 국제출원의 경우 출원인은 국제출원일 당시에 국제출원서(Box No. VIII(v))에서 '신규성 상실의 예외에 관한 선언'을 할 수 있고 특허법 제201 조제5항에 따라 국제출원서는 우리나라 특허출원의 출원서로 간주되는바, 국제출원서에 위 선언이 포함된 것이 확인된 경우에는 특허법 제30조제2항 에 따른 취기 기재가 올바르게 된 것으로 취급하여야 한다. 즉, 위 선언이 국제출원서에 기재되고 기준일로부터 30일 내에 증명서류가 적법하게 제출 되었다면 제200조에 따른 서면이 제출되지 않은 경우라도 제30조제2항의 요건을 갖춘 것으로 인정하고 심사를 진행한다(PCT 규칙 4.17 참조).[PCT 규칙4.17]").

다 분할출원의 공지예외적용 3가지 분류 및 허용 기준 제안

분할출원이 공지예외를 주장하는 경우는 아래의 그림과 같이 세 가지 경우로 나눌 수 있다.

〈그림3〉 분할출원의 공지예외적용



① 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았으나 1년 이내에 분할출원을 하는 경우, ② 원출원 시 공지예외주장을 하였으나 1년이 경과한 후 분할출원 시 공지예외주장을 하는 경우, ③ 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 1년이 경과한 후 분할출원 시 공지예외주장을 하는 경우.

①의 경우, 공지예외기간 내에 분할출원이 이루어졌기 때문에 분할출원 시 공지예외 주장이 가능하다. 원출원에서 공지예외주장을 하지 않았으므로, 분할출원 시 공지예외 절차를 새롭게 준수해야 한다. ②의 경우, 원출원 시 공지예외주장을 하였더라도 분할출원 시 절차적 요건에 따라 공지예외주장을 새롭게 해야 한다. ③의 경우 원출원 시 공지예외주장을 하지 않았기 때문에 1년이 경과한 후에는 분할출원에서 공지예외주장을 할 수 없다. 이를 허용하는 것은 앞서 설명한 바와 같이 특허법 제30조 제2항 및 제3항의 규정을 무력화하고, 특허법 제52조 제2항의 취지를 퇴색시키는 결과를 초래한다.

결론적으로, 공지예외제도가 합리적으로 운용되기 위해서는 공지예외 주장 시기를 놓친 원출원에 대해 분할출원 시에도 절차적 요건을 엄격히 준수해야 한다. 또한 원출원 시 공지예외주장을 하지 않고 공지예외기간이 경과한 분할출원에 대해서는 공지예외주장을 불허하는 것이 타당하다고 본다. 본 논문이 제시한 분석과 논거가 향후 관련 법리와 실무의 발전에 기여할 수 있기를 기대하며, 이를 통해 공지예외제도와 분할출원제도가 보다 합리적이고 명확한 방향으로 정립되기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 김관식, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구 제28권 제2호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022.
2. 김동준, “특허법상 분할출원제도 개선방안”, 경영법률 제19권 제1호, 한국경영법률학회, 2008.
3. 윤기승, “특허법상 공지예외적용에 관한 연구”, 국제법무 제11집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2019.
4. 이규호 외 3명, “우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰-조문별 특허법해설”, 특허청 연구보고서, 2007.
5. 이주환, “특허법상 분할출원의 공지예외주장 - 대법원 2022. 8. 31. 선고 2020후11479 판결을 중심으로 -”, 2022 TOP10 특허판례 세미나, 한국특허법학회, 2022.
6. 임석재·한규현, 『특허법』, 박영사, 2017.
7. 정차호, "IP5 특허청의 본인공개예외(Self-Disclosure Exception)제도", 정보법학 제17권 제2호, 한국정보법학회, 2013.
8. 조영선, 『특허법 3.1』, 박영사, 2023.
9. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 131호, 특허청, 2023.
10. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 94호, 특허청, 2016.
11. 특허청 특허제도과, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청 예규 97호, 특허청, 2017.

12. 特許庁, “平成 30年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き”, 2020.

13. 特許庁, “特許 · 実用新案 審査基準”, 2020.

14. 特許庁, “平成 23年 改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用 を受けるための出願人の手引き”, 2013.

15. Min Son, “Grace period but no safeguards for missing deadlines in South Korea”, ManagingIP, 2021.

16. Allegro, “1 Year Grace Period in Japan – Exceptions to Loss of Novelty”, Allegro, 2021.